

他组织等先行表达投案意愿或者委托亲友先代为投案的情形较为普遍。此种情形应当视为自动投案。

（二）投案对象的限定

处于境外的犯罪嫌疑人向我国驻外大使馆、领事馆等机构投案的，可以视为自动投案。具体理由如下：第一，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》规定，犯罪分子向所在单位等办案机关以外的单位、组织或者有关负责人员投案的，应当视为自动投案。我国驻外大使馆、领事馆等机构未超出“办案机关以外的单位、组织”的范畴。第二，我国驻外使领馆等机构作为我国派驻的常设外交代表机关，犯罪嫌疑人向我国驻外使领馆主动投案可以视为向我国国家机关投案。第三，根据部分双边刑事司法协助条约，我国驻外使领馆等机构可以有限制地开展部分司法行为。例如，《中华人民共和国和加拿大关于刑事司法协助的条约》第十八条规定，一方可以通过其派驻在另一方的外交或领事官员向在该另一方境内的本国国民送达文书和调查取证，但不得违反驻在国法律，并不得采取任何强制措施。

三、投案时间的限制

境外劝返与一般自首中自动投案的投案时间也可存在差异。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款的规定，一般自首中的自动投案的时间应当是犯罪事实未被司法机关发觉，或者虽然被发觉，但是犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施之前。但是，在境外劝返案件中，无论是司法机关工作人员还是经司法机关授权的犯罪嫌疑人亲友对犯罪嫌疑人进行劝返时，司法机关必然已经掌握了该犯罪嫌疑人的犯罪事实，不属于犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉的情形。而且，在诸多境外劝返案件中，犯罪嫌疑人已经因非法移民等问题被所在国羁押，或者被请求国应我国有关引渡、遣返等请求后已经对犯罪嫌疑人采取羁押、监视居住等强制措施。

但笔者认为，经劝返后自愿从境外回国的，可以视为主动投案。具体理由

如下：第一，实践中，境外羁押不能一概视为我国司法机关已经对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。因为国家间法律制度的不同，犯罪嫌疑人在境外被采取羁押、监视居住等强制措施并不代表该犯罪嫌疑人很快就能被移送或者遣返回国。

第二，从自首的立法目的来看，犯罪嫌疑人自愿回国，有利于提高归国的效率，节约司法资源，这与自首的立法目的是完全契合的。第三，根据事由同一性原则，境外羁押等事由与国内刑事立案事由并非必然存在对应关系。实践中，有不少境外劝返案件中，犯罪嫌疑人被羁押的理由是非法移民被移民局等机关羁押等，而非系因涉嫌请求国所请求之罪名而被被请求国司法机关采取羁押、监视居住等强制措施，本案正是此种情形。

综上所述，在国际追逃追赃案件中，外逃人员在被请求方就引渡请求作出决定前明确表达主动投案意愿的，即使其已经被被请求方羁押，后回国到案接受办案机关处理的，仍可以视为主动投案。本案中，被告人陈某自2019年5月16日被公安机关上网追逃至2023年2月一直拒不到案，后因其持双重国籍违反A国移民局有关规定而被A国移民局羁押，不回国将被遣返至新入籍的B国或继续羁押在A国移民局，陈某才选择回国归案。虽然陈某的到案具有一定的被动成分，但是其毕竟是接受劝返后在尚有其他选择时自愿回国，可以视为自动投案。陈某虽然系经劝返自愿回国，但是其未如实供述自己的主要犯罪事实，依法不能认定其具有自首情节。

被告人当庭翻供对其行为的认定

——刘某、欧某诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

贵州省息烽县人民法院(2022)黔0122刑初106号刑事判决书

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

2022年7月，被告人刘某、欧某为牟取非法利益，经共谋后购买有其他人引流好的昵称为“某思”的QQ号（该QQ号实际并非某演员使用的QQ号）引诱粉丝加入，并冒用演员身份进行诈骗。同年7月19日，被害人戴某某使用其父亲的手机添加该QQ号后，被告人刘某、欧某遂以演员身份告诉戴某某，只要参与游戏，支付58.88元即可以获得演员签名照片，并且承诺支付58.88元返588元。戴某某支付了58.88元后，刘某、欧某又以演员身份让其加财务人员的QQ号，告诉她财务人员会退还她588元并且向她确认信息，邮寄签名照等。戴某某加了财务QQ以后，按照财务人员的要求扫描二维码，陆续转账4万余元。后戴某某反应过来其应该是遭遇诈骗，要求对方退款，但所谓的财务人员早已查无音讯。随后，戴某某向公安机关报警，经过公安机关侦查，戴某某喜欢的某演员和所谓的财务人员均系刘某、欧某假扮。

【案件焦点】

1. 刘某与欧某的讯问笔录不一致能否认定二人实施了诈骗行为；2. 欧某当

庭翻供后又如实供述是否可以认定为自首。

【法院裁判要旨】

贵州省息烽县人民法院经审理认为：被告人刘某、欧某以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关对被告人刘某、欧某犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以确认。在共同犯罪过程中，两名被告人互相配合、各有分工，所起地位作用相当，不宜区分主从。被告人刘某在公安机关供述自己罪行后当庭翻供，依法不应认定为坦白；欧某经公安机关电话通知，在未被采取强制措施前主动投案，并如实供述了犯罪事实，其当庭翻供后又如实供述了犯罪事实，依法应认定为自首，同时其自愿认罪认罚，并已签字具结，可从轻、减轻处罚。案发后，被告人刘某、欧某亲属已代为赔偿被害人损失并取得谅解，可酌定从轻处罚。庭审中，被告人刘某否认参与实施诈骗，后又称其仅参与了聊天环节，后面要求转款等诈骗行为系欧某负责操作，经查，被告人刘某、欧某到案后在公安机关多次供认冒用演员QQ号对被害人实施诈骗的具体方式及过程，供述内容前后稳定一致，二被告人供述在犯罪过程中各自的分工上虽有出入，但在案证据能够证实二人共同参与实施诈骗的事实，虽然被告人刘某在庭审中当庭翻供，提出当时系受到办案民警威胁、诱骗才作出上述供述，但本院在庭前及庭后两次提讯时均明确告知其有申请非法证据排除的权利，其亦提出在公安机关审讯时未受到刑讯逼供，并明确表示不申请非法证据排除，故被告人刘某否认其所作供述不具有合理性，且刘某庭审中翻供其辩解与全案证据矛盾，亦不能作出合理解释，结合其他在案证据相互印证，对被告人刘某的庭前供述应予采信，故对刘某的辩解意见法院不予采纳。被告人欧某的辩护人提出被害人损失已获赔偿，并出具了谅解书，希望对其从轻处罚的辩护意见，法院予以采纳。量刑方面，结合本案被告人的犯罪情节、涉案金额及具体量刑情节，公诉机关对被告人欧某提出的量刑不当，经法院建议，公诉机关未作调整，法院依法作出判决；对被告人刘某的主刑量刑过重，罚金刑不当，法院亦不予采纳，并依法予以调整。据此，判决如下：

- 一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；
 - 二、被告人欧某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。
- 案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案的争议焦点在于刘某与欧某的供述互相矛盾，是否能认定其二人实施了诈骗行为，欧某在庭审中当庭翻供后又如实供述的行为能否认定为自首。

一、被告人之间的供述相互矛盾，是否可以定罪

在本案中，被告人刘某在公安机关供述了其与欧某共谋并实施诈骗的主要过程，在庭审过程中，被告人刘某及欧某均翻供表示其在公安机关的供述不属实。在第二次庭审过程中，被告人欧某又表示其在公安机关的供述属实，被告人刘某仍然表示其在公安机关的供述系受到刑讯逼供作出的有罪供述，不应当作为证据使用。但在庭前及庭后两次提讯时均明确告知其有申请非法证据排除的权利，其亦提出在公安机关审讯时未受到刑讯逼供，并明确表示不申请非法证据排除。被告人刘某在庭后提讯时表示，其在公安机关作出有罪供述是因为公安机关告知只要承认了犯罪事实，就可以办理取保候审。根据被告人刘某的社会阅历及文化程度，其供述系在公安机关的引诱下作出的有罪供述的理由不能成立。公安机关讯问笔录同步录音录像也可以证明，公安机关在侦查过程中审讯程序合法，不存在刑讯逼供，其在公安机关作出的有罪供述应当作为证据使用。被告人刘某与欧某之间的供述，在具体分工和犯意提起上相互矛盾，但均能准确供述实施诈骗过程的细节，被害人被骗经过及具体转账金额，可以认定被告人刘某、欧某实施诈骗行为的事实，被告人刘某、欧某的行为应当认定为诈骗罪。因其二人互相配合、各有分工，所起地位作用相当，不宜区分主从犯。

二、在庭审中翻供又如实供述的，是否认定为自首

本案中，被告人欧某系经公安机关电话通知后到案，到案后其如实供述犯罪事实，应当认定为自首，但在第一次庭审中，被告人欧某当庭翻供，在第二次庭审中，被告人欧某又如实供述犯罪事实，是否继续认定其行为构成自首。

犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行的，是“自首”。对这一点的理解，应该是：犯罪嫌疑人在作案后，自己主动、直接地投案，同时如实供述自己的罪行的，认定为自首。这一规定，其中包括两点：犯罪以后自动投案；如实供述自己的罪行。犯罪嫌疑人在投案时，如实供述了自己的罪行，但在以后的供述中，推翻原供，否认或部分否认犯罪。这种情况不能认定为自首，因为其所作的虚假供述不符合自首的“如实供述自己的犯罪事实”的条件要求，也就不能对其认定自首。但如果犯罪分子思想上有反复，在如实供述自己罪行后又否定或推翻了自己的罪行，经过批评、教育后，在一审判决前又如实供述的，仍应认定其为自首。本案中，被告人欧某在公安机关侦查过程中如实供述其犯罪事实，在第一次庭审中当庭翻供，在第二次庭审时又如实供述，应对其认定自首。

本案系冒充演员诈骗未成年人财物的典型案例，具有较强的针对性。本案中被告人刘某、欧某利用未成年人涉世未深、社会经验缺乏、容易轻信对方、易受外界诱惑等特点实施诈骗，哄骗未成年人转账汇款，严重侵害未成年人合法权益，也给其家庭造成经济损失。人民法院对刘某、欧某依法处罚，充分体现了人民法院坚决保护未成年人合法权益，严厉惩处针对未成年人犯罪的鲜明立场。对此，学校、家庭要加强对未成年人的防骗教育，引导未成年人理性追星，切实增强网络防范意识，不要轻信网络中演员效应及返利活动，防止被诱骗落入诈骗陷阱。

编写人：贵州省息烽县人民法院 张清 钟亚兰

取保候审期间脱逃又主动投案 如实供述犯罪事实的能否认定自首

—— 李某盗窃案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省淄博市淄川区人民法院(2024)鲁0302刑初105号刑事判决书

2. 案由：盗窃罪

【基本案情】

2022年11月22日凌晨，被告人李某与他人(另案处理)到某小区，盗窃刘某虎年茅台酒1瓶、大苏烟1条；盗窃肖某茅台精品酒4瓶、六瓶装茅台王子酒3箱、六瓶装茅台飞天酒3箱、茅台飞天酒4瓶；盗窃郭某六瓶装茅台王子酒1箱、六瓶装五粮液酒1箱、硬中华烟1条、黄鹤楼烟1条、蓝八喜烟1条、天子烟1条、红方印烟1条。经鉴定，盗窃物品总价值人民币93610元。经查，被告人李某在取保候审期间脱逃，公安机关网上追逃，后在逃人员李某在家属的陪同下投案自首。

【案件焦点】

取保候审期间脱逃，又主动投案如实供述犯罪事实的，能否认定为自首。

【法院裁判要旨】

山东省淄博市淄川区人民法院经审理认为：被告人李某以非法占有为目的，伙同他人秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。本案系一般共

同犯罪，不宜区分主从犯。被告人李某系坦白，对其可从轻处罚；被告人李某自愿认罪认罚，对其可从宽处理。被告人李某积极退赔被害人损失，可酌定从轻处罚。据此，判决：

被告人李某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元；追缴到案的涉案款93610元，依法退赔被害人。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款中规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。司法实践中，存在这样一种情形：犯罪嫌疑人在取保候审期间脱逃后又主动投案如实供述犯罪事实的，这种情况下是否应认定为自首。相关法律法规和司法解释没有作出明确规定，对此存在两种不同观点。一种意见认为构成自首，理由是犯罪嫌疑人逃跑已经受到没收保证金等法律制裁，脱逃后自动投案仍然符合自动投案的本质属性，有利于其认罪悔过，减少司法成本；另一种意见认为不构成自首，理由是认定自首无疑是传达、鼓励犯罪嫌疑人脱逃后仍能获得从轻处罚，不能体现法律的公平公正与权威，与自首制度的价值相冲突。

应当说第二种意见是正确的。理由是：

一、认定自首不符合自动投案的成立要件

《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第一条第一项规定，自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案……

由此，自动投案需要具备自动性和时间要求。自动性指行为人主动将自己置于司法机关控制之下接受审查。在涉嫌犯罪的情况下，犯罪嫌疑人在取保候审期间脱逃，脱离司法机关的控制，躲避司法机关追诉，不符合自动性要求。同时，根据《解释》规定，自动投案是在犯罪以后，尚未被采取强制措施之前（本文不讨论特殊自首），“尚未”应是指在案发后一直未曾受到讯问、未采取

强制措施。有观点认为，犯罪嫌疑人在取保候审期间脱逃，强制措施效力消失，应视为未归案，再次主动投案符合自首条件。若按此逻辑，无论是侦查、审查起诉还是审判阶段，任何时间都有成立自首的可能性，自首认定标准随时可能发生变化，自首的适用将被反复调整，强制措施的效力将会大打折扣，法律稳定性和权威性将受到挑战；同时《解释》规定，犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。也就是在投案之后的侦查、审查起诉以及审判阶段均不应有逃跑的行为，否则不应认定为自首，对于犯罪嫌疑人逃跑后又主动归案的行为应理解为对其在取保候审期间逃跑行为所产生后果的事后弥补。以此类推，《解释》中“犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的……应当视为自动投案”的规定，针对的也是犯罪后始终未被抓捕归案的在逃犯罪人员主动投案的情形。

二、认定自首不符合罪责刑相适应原则

对具有自首情节的行为人是否从宽处罚以及从宽处罚的幅度，应当综合考虑其犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、危害后果、社会影响以及行为人的主观恶性和人身危险性进行量刑。对取保候审期间脱逃后又自动投案的犯罪嫌疑人，适用自首不能与其认罪悔罪的态度、人身危险性、造成的社会影响等相统一，有违罪责刑相适应原则，不利于法律的公平公正。

一方面，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条规定了被取保候审人的义务及违反义务的法律后果，而犯罪嫌疑人仍然不顾法律约束，公然挑战国家司法追诉程序的权威，躲避司法机关追究，其人身危险性相对较高，同时对其犯罪行为不能深刻认识到错误，没有真诚认罪悔罪态度，仍有再犯的可能性，即便后来又主动投案，也不能因此忽视其之前的逃跑行为，不可避免是否仍然存在思想上的反复，对社会稳定性有着较大的威胁。另一方面，适用自首制度容易导致量刑失衡。对于未脱逃的犯罪嫌疑人与脱逃的犯罪嫌疑人相同适用自首量刑，容易让人产生对法律的错误理解，不利于实现法律的公平公正。当然，对于取保候审期间脱逃后又主动投案的，也有其积极价值，不认定该情形属于自动投案，并不影响将其作为归案后如实供述、认罪态度较好等酌定从宽情节

在量刑时予以考虑，完全可以做到罪责刑相适应，也在一定程度上起到鼓励违反强制措施逃跑的犯罪嫌疑人积极主动投案的作用。

三、认定自首不符合立法价值追求

《中华人民共和国刑法》实行宽严相济的刑事政策，落实惩罚与教育相结合。自首制度对于鼓励犯罪人悔过自新、节约司法成本，提高司法审判效率以及维护社会稳定具有重要意义。然而犯罪嫌疑人在取保候审期间脱逃行为，即便是后来又主动投案，认定自首实际上不利于犯罪嫌疑人深刻认识到自身脱逃行为及犯罪行为的错误，同时也造成了司法资源的浪费。

一方面，该行为认定自首无疑是鼓励犯罪嫌疑人可以不受法律强制措施下的约束而肆意妄为，只要最后能主动投案仍然可以获得法律的从轻处罚，显然这并不能让犯罪嫌疑人认识到触犯法律所带来的后果，一个对法律都没有敬畏心的人是无法通过法律制裁来达到法律惩罚与教育的目的。另一方面，评价是否造成司法资源的浪费，不应将脱逃和投案行为分开评价。犯罪嫌疑人的脱逃导致被公安机关网上通缉消耗公安侦查资源、加大追捕成本，影响法院正常审理程序的开展，加大改造教育成本……即便后来主动投案，但是这些司法成本可以不额外消耗，因为犯罪嫌疑人的逃跑而加大了司法机关人力、物力、财力的投入，并不能达到节约司法资源，提高审判效率的效果，违背了自首制度设立的立法精神。

综上，取保候审期间脱逃，又主动投案如实供述犯罪事实的，不能认定为自首，但可以结合犯罪嫌疑人归案后如实供述、认罪态度较好等酌定从宽情节综合确定量刑。

编写人：山东省淄博市淄川区人民法院 王子莹

经侦查机关以其他事由通知到案行为的定性^①

——许某某掩饰、隐瞒犯罪所得案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第一中级人民法院(2024)沪01刑终25号刑事判决书

2. 案由：掩饰、隐瞒犯罪所得罪

【基本案情】

被告人许某某系某机场地面服务公司高级管理人员。2020年7月、8月，许某某招募、安排、指挥多人在明知钱款来路不正的情况下，通过用他人的支付宝账户接收钱款、在多个账户之间流转、转换成虚拟币、再转回上家账户的方式，转移涉案赃款。其中，涉及他人被诈骗钱款。公安机关在排查出许某某系网上追逃人员后，为保障抓捕安全，于2022年10月2日以对许某某所在单位进行火种安全检查的名义，电话通知许某某到派出所配合检查。许某某接通知到案后未第一时间供述罪行，但在公安民警出示拘留证、网上追逃文件等材料后如实供述基本犯罪事实。此后，许某某退赔并取得谅解。

【案件焦点】

经侦查机关以其他事由通知到案的行为人是否构成“自动投案”。

^①入库案例，参见人民法院案例库2024-18-1-300-001。

【法院裁判要旨】

上海市松江区人民法院经审理认为：被告人许某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。许某某在明知自己是掩饰、隐瞒犯罪所得的涉案人员，接公安机关电话传唤后主动到案，后如实供述基本犯罪事实，符合自首的认定条件，依法对其减轻处罚。据此，以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人许某某有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币2万元；退缴在案的钱款，发还被害单位。

一审宣判后，公诉机关上海市松江区人民检察院提起抗诉，认为原判自首认定错误，导致对许某某适用减轻处罚不当。上海市人民检察院第一分院支持抗诉。

上海市第一中级人民法院经审理认为：原审被告人许某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原判定罪正确且诉讼程序合法。根据在案证据，公安机关发现许某某系在逃人员后，已经掌握其涉嫌犯罪的证据，因不确定其是否在本市，为避免“打草惊蛇”，故实施抓捕计划，以安全检查的名义电话通知许某某至派出所。公安机关的电话通知距离案发已超过两年，许某某作为机场地面服务公司高级管理人员，配合安全检查系其职责范围。故而，判断自首成立与否的关键在于许某某到案后的供述时间。许某某到案之日未第一时间供述罪行，直至办案人员出示拘留证、网上追逃文件等材料，才如实供述基本犯罪事实，且许某某关于到案前知道公安机关真实意图、确已准备投案的供述缺乏其他证据印证。综上，能够认定许某某在一定程度上相信了公安机关通知其配合检查的理由，表明其始终抱有侥幸和试探的心理，而不具有主动投案的意愿。原判认定许某某具有自首情节不当，依法应予纠正。抗诉机关的抗诉意见及上海市人民检察院第一分院的出庭意见正确，应予支持。许某某到案后如实供述自己的罪行，积极退赔并取得谅解，可以从轻处罚。据此，依法判决如下：

一、维持上海市松江区人民法院(2023)沪0117刑初1260号刑事判决第二项，即“二、退缴在案的钱款，发还被害单位”；

二、撤销上海市松江区人民法院(2023)沪0117刑初1260号刑事判决第一项，即“一、被告人许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九

个月，并处罚金人民币2万元”；

三、原审被告人许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元（已缴纳）。

【法官后语】

自动投案是一般自首成立的首要条件。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）规定，自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。据此，自动投案是一个包含了主观要件的客观行为。现实生活中，经侦查机关以其他事由通知到案（以下简称“他事由”）是一种较为常见的归案方式。在该种情形中，投案的客观行为比较容易判断，投案的主观要件即投案的自动性往往是司法实践中的认定难点。

一、经其他事由通知到案认定自动投案原则上应当从严把握

自动投案的司法认定应当符合自首制度的立法本意。其一，从事实认定的准确性来看，与经涉案事由通知到案相比，经他事由通知到案的行为人有更多试探侦查机关态度的机会，极易产生侥幸心理，侥幸心理与投案意愿都是隐秘的心理活动，司法实践中难以区分，容易引发事实认定的重大错误，故而认定自动投案应当极为审慎。其二，从行为人的主观恶性来看，即使行为人确有投案意愿，也是在接到通知后才作出投案选择，通知虽然不限制行为人的人身自由，却会对其心理造成一定的威慑和压力，故其认罪悔罪的态度及投案的自动性远不如未经通知自动归案的行为人，在认定自动投案的严格程度上有必要进行区分。其三，从节约办案资源的动因来看，司法实践中，侦查机关往往是已经掌握了行为人涉嫌犯罪的主要证据，但因无法确定其行踪轨迹，或认为其仍有较大的人身危险性以及逃避侦查的可能性，才会以其他事由将行为人“诱骗”到案，到案后再立即对其进行讯问或抓捕。故从本质上来说，案件侦破依靠的是侦查机关的努力，抓捕效率的提升也主要源于侦查机关实施了周密有效的抓捕计划，与典型的自动投案行为相比，经他事由通知到案的行为并未有效

地节约司法资源。鉴此，对于侦查机关已经掌握犯罪证据并以他事由通知行为人到案的，应当从严把握自动投案的认定标准，尤其是投案意愿的认定标准。在此种情形中，行为人必须具有强烈的认罪悔罪态度，主观恶性、人身危险性明显降低，才可成立自动投案，否则不应认定自动投案。

二、经其他事由通知到案后未第一时间如实供述的一般不认定为自首

经其他事由通知到案的情形中，行为人能够第一时间如实供述主要犯罪事实的，主观恶性明显减低，应当认定为自动投案；到案后矢口否认与犯罪案件有任何关系的，完全不具有认罪悔罪态度，不应认定自动投案。到案后既没有立即供认，也没有矢口否认的，应结合个案情况具体分析。

第一，对于侦查机关尚未掌握犯罪证据的，行为人经通知到案既体现了认罪悔罪的主观态度，亦节约了司法资源，符合自首制度的立法本意，可以适用《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》规定的“尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的”，视为自动投案。

第二，对于侦查机关已经掌握犯罪证据的，行为人必须到案后第一时间如实供述基本犯罪事实，才可成立自动投案。其中，“基本犯罪事实”是指定罪的最基本事实，包括时间、地点、人物等基本要素。“第一时间”既指排除客观阻碍因素(如有)后最早的时间点，也指先于侦查机关的时间点。之所以作此严格要求，在于行为人到案后只可能有三种互不相容的心理状态——自动投案的心理、侥幸试探的心理或者完全出于错误认识。后两者决定了行为人到案后不可能第一时间提及犯罪，足以阻断投案的自动性，行为人之后再形成的认罪悔罪态度不能视为归案时的主观意愿。若行为人到案后立即被侦查机关采取强制措施或出示犯罪证据的，实际上这也是一种客观阻碍因素，但该因素意味着行为人已丧失先于侦查机关作出意思表示的机会，尚未来得及主动提及犯罪事实的，原则上不成立自动投案，除非有充分证据印证行为人确已准备投案。

形迹可疑型自首的把握认定

—— 阮某抢劫案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省泰州市中级人民法院(2023)苏12刑终85号刑事判决书

2. 案由：抢劫罪

【基本案情】

2022年5月13日凌晨4时许，被告人阮某采用先扒窗再开锁的方式，进入被害人以某租住的车库内实施盗窃，窃得以某的手机1部(价值人民币4600元)，以某发现后，抓住阮某手臂并呼喊，阮某为脱身即拳击以某的面部、臂部等处，致以某受伤，阮某迅即逃离现场。经鉴定，以某损伤程度已构成轻微伤。阮某因形迹可疑，在公安机关对其进行一般性排查时主动交代罪行。阮某归案后积极赔偿被害人损失并得到谅解，所劫手机由公安机关依法扣押并发还被害人。

【案件焦点】

对形迹可疑型自首的准确把握认定。

【法院裁判要旨】

江苏省泰州市海陵区人民法院经审理认为：被告人阮某以非法占有为目的，入户秘密窃取他人财物，为抗拒抓捕而当场使用暴力，其行为已构成抢劫罪，应依法惩处。阮某归案后如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚。阮某积极

预交罚金、赔偿被害人损失并得到谅解，酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第一项、第二百六十九条、第五十六条第一款、第六十七条第三款之规定，以抢劫罪判处被告人阮某有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币5000元。

一审宣判后，阮某提出上诉。

江苏省泰州市中级人民法院经审理认为：上诉人阮某以非法占有为目的，入户秘密窃取他人财物，为抗拒抓捕而在户内当场使用暴力，其行为已构成抢劫罪，应依法惩处。本案中阮某因形迹可疑，在公安机关对其进行一般性排查时主动交代罪行，应当视为主动投案，其归案后如实供述了全部犯罪事实，构成自首，依法可以减轻处罚。辩护人提出的“阮某构成自首”的意见予以采纳。上诉人阮某积极预缴罚金、赔偿被害人损失并得到谅解，酌情对其从轻处罚。

江苏省泰州市中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项，《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条第一项、第六十七条第一款之规定，作出如下判决：

一、撤销江苏省泰州市海陵区人民法院(2022)苏1202刑初204号刑事判决；

二、上诉人(原审被告)阮某犯抢劫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币5000元。

【法官后语】

本案的争议焦点是上诉人(原审被告)阮某是否构成自首，而是否构成自首的认定关键在于阮某是形迹可疑还是有犯罪嫌疑。研判时存在两种不同意见。

第一种意见认为，公安机关已掌握罪证确定了阮某的犯罪嫌疑，其属于罪行已被司法机关发觉，之后的主动交代犯罪事实，应当认定构成坦白而非自首。

第二种意见认为，根据二审期间公安机关出具的阮某归案情况说明，应当认定案发后公安人员至阮某家中盘问时，仅是认为其形迹可疑，其主动交代犯

罪事实，应当视为自动投案，构成自首。

经二审审理查明，被害人以某报案后，公安人员经调取小区监控录像，发现阮某形迹可疑，至其家中进行盘问时，阮某主动交代了犯罪事实。该事实得到二审庭审中出庭检察员当庭宣读的“以某被抢劫案”的侦破情况说明等证据的证实。本案一审中，公安机关曾经出具归案情况说明，该情况说明与二审中出具的情况说明存在一定差异，区别在于前者认定已经掌握罪证确定了阮某的犯罪嫌疑，而后者认为未掌握实质性罪证，只是认为阮某形迹可疑。

二审生效判决综合全案事实和证据审查采信了二审公安机关出具的侦破情况说明，采纳第二种意见，认定阮某构成自首。理由如下：(1) 本案中阮某属于“形迹可疑”的状态。公安机关接到报警后，调取了小区内的监控录像进行研判，发现一男子在案发时段大步从被害人所住楼栋向北跑动，经视频追踪发现男子在小区内多处出现、走动，且当日凌晨4时出现在被害人租住房附近的小区南门，根据侦查经验将其圈定为排查对象是合理的，但因被害人未看到犯罪嫌疑人的相貌，此时公安人员尚未掌握实质性的犯罪证据，是基于阮某可疑表象，主要依据常识、常情、常理和公安工作的经验直觉形成的推测，此时形成的对阮某状态的判断属于“形迹可疑”。而犯罪嫌疑是对事实证据进行分析、判断后形成的针对性推定，须以事实证据为依据，此时公安虽然对视频监控中的黑衣男子进行人脸识别，确认为阮某，但阮某居住在案发小区，租住房离被害人住处相距不远，其从案发地点附近经过、出现在小区南门正常行走亦属正常，单凭此疑点表象并不足以构成证据线索指向阮某并锁定其犯罪嫌疑。(2) 公安机关上门找阮某调查属于盘问。案发当天下午公安机关至阮某家，是作为可疑对象的排查，未作为犯罪嫌疑人立案，在调查过程中阮某主动交代了犯罪事实，并带领公安人员起获赃物。从公安机关排查询问的性质上看，应当认定为盘问，而非讯问调查。(3) 是否属于形迹可疑还是锁定犯罪嫌疑属于分析意见，应当依法判定。公安机关出具的情况说明，主要在于反映侦破案的真实情况，采取什么措施、如何开展排查、怎样关联犯罪嫌疑人，在此过程中会不断产生分析意见，如何确认当时的行为性质，有赖于最终的司法认定。本案

一、二审所举证前后两份归案(侦破)情况说明对于破案的经过、细节的描述基本一致,不同之处在于运用视频监控研判时如何评价形迹可疑还是犯罪嫌疑。在较多案件中,可以根据视频监控掌握犯罪分子的特征,建立起与案件的直接关联,锁定其犯罪嫌疑;而有些案件中视频监控尚未建立起较强的关联,只是作为可疑人员对待,需要通过进一步侦查发现犯罪分子,两种情形应当区别对待。

本案中,侦查人员经重新回顾评析,纠正了先前情况说明中的意见,二审法院认同并予以采纳。阮某被公安机关上门盘问时仅是一般性怀疑,存在其可能与该案存在联系的疑点,但证据线索并未达到针对性怀疑“犯罪嫌疑”的程度,此时阮某如实交代犯罪事实并带领公安人员起获赃物的行为,根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定,阮某系罪行未被发觉,仅因形迹可疑受到公安机关盘问后主动交代自己所犯罪行,应当视为自动投案,故阮某构成自首。

编写人:江苏省泰州市中级人民法院 徐佼 蔡萍

重大立功情节中如何认定提供线索对侦破案件或 抓捕犯罪嫌疑人具有“实际作用”

——柳某受贿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市顺义区人民法院(2023)京0113刑初321号刑事判决书

2. 案由:受贿罪

【基本案情】

2014年初至2023年初，被告人柳某利用担任某镇党委副书记、镇长，某区城市管理委员会党组书记、主任的职务便利，多次收受当地建筑工程企业法定代表人、实际控制人给予的款物共计人民币274万余元，并为相关人员承接工程项目等提供帮助。柳某于2023年2月2日被某区会查获。被告人柳某到案后，提供了其之前听闻的王某、熊某二人于2003年至2004年将他人打死的情况，并提供了王某、熊某藏匿的大致地点信息，经查，该两名犯罪嫌疑人为一起已经破获的故意伤害致死案件的逃犯，公安机关根据柳某提供的信息并结合技术侦查手段锁定了该两名犯罪嫌疑人并予以抓获。

【案件焦点】

被告人柳某虽然提供了其知晓的王某、熊某实施犯罪行为及大致藏匿地点的信息，但该案件已经被公安机关侦破，且仅提供了犯罪嫌疑人大致的藏匿地点区域，公安机关另外借助了技术侦查手段才抓获犯罪嫌疑人，在这种情况下，柳某提供的相关信息是否能够认定对于侦破案件或者抓捕犯罪嫌疑人有“实际作用”。

【法院裁判要旨】

北京市顺义区人民法院经审理认为：经查，被告人柳某向公安机关提供的王某、熊某实施犯罪行为的线索属于已侦破案件的信息，案件的相关犯罪嫌疑人情况属于公安机关掌握的事实，故柳某检举揭发不属于“提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实”的情形，但是，现有证据足以证明公安机关借助柳某提供的两名犯罪嫌疑人藏匿地点信息，成功抓获了犯罪嫌疑人，根据公安机关对抓获犯罪嫌疑人具体过程的说明，应当认定柳某提供的线索对抓捕犯罪嫌疑人具有实际作用，柳某属于“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”。被告人柳某提供线索协助司法机关抓捕可能被判处无期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人，构成重大立功。

北京市顺义区人民法院对被告人柳某犯受贿罪依照《中华人民共和国刑法

法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第二项、第二款、第三款，判决如下：

- 一、被告人柳某犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元；
- 二、被告人柳某退缴在案的人民币2741570元，依法予以没收，上缴国库。案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条第一款之规定，犯罪分子有检举、揭发他人重大犯罪行为，经查证属实；提供侦破其他重大案件的重要线索，经查证属实；阻止他人重大犯罪活动；协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有重大立功表现。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的规定，据以立功的线索或者协助行为对于侦破案件或者抓捕犯罪嫌疑人要有实际作用。提供的线索或者协助行为对于其他案件的侦破或者其他犯罪嫌疑人的抓捕不具有实际作用的，不能认定为立功表现。

结合本案，判断柳某的立功行为的类型以及其提供的信息是否对侦破案件或抓捕犯罪嫌疑人具有“实际作用”，主要考虑了以下几个因素：

第一，柳某检举揭发不属于“提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实”的情形。经公安机关核查，柳某提供的线索涉及2003年在北京市通州区发生的一起故意伤害致死案中两名在逃嫌疑人熊某、王某，该案立案后即已经查明系王某带领陈某及熊某等人将被害人殴打致死，该案已于当年告破，陈某已被判决，熊某、王某在逃。故该案件属于已经明确了犯罪事实、确定了相关犯罪嫌疑人的已侦破案件，案件的相关犯罪嫌疑人情况已经属于公安机关掌握的事实，柳某并非“提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实”。

第二，柳某提供的线索不仅涉及王某、熊某涉嫌犯罪的情况，还指出了王某、熊某藏匿的大致地点，如果该线索对公安机关抓捕犯罪嫌疑人具有“实际作用”，柳某即属于“协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人”而成立重大立功。

